

0001407-12.2018.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/08/2022

... um senhor de idade, morador do bairro, para uso e tráfico de entorpecentes. As compras eram feitas com o dinheiro extorquido do senhor de idade. Foram até o local, e tiveram uma conversa informal com o senhor de idade, mora sozinho, confirmou que a acusada pedia dinheiro, e por saber que a acusada era envolvida com o tráfico, entregava dinheiro, por medo. Em seguida, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001407-12.2018.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001407-12.2018.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Ofício - 1262/2018 - 4º

Distrito Policial de Mogi das Cruzes, 1262/2018 - 4º Distrito Policial de Mogi das Cruzes, 1124/2018 - 4º Distrito Policial de Mogi das Cruzes

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDIA FRANCISCA LAU

L

Juíza de Direito: Dra. Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

CLAUDIA FRANCISCA LAU, qualificada nos autos, foi denunciada pela Justiça Pública e devidamente processada como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 18 de julho de 2018, por volta das 09h40min, na Rua Virgínia Eugenia Aurebach, Taiaçupeba, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, trazia consigo e guardava, cerca de: (i) 25,9g (vinte e cinco gramas e nove decigramas) da droga TetraidrocanabinoL-THC (maconha), acondicionada em 10 (dez) invólucros de plásticos translúcidos fechados por nó; (ii) 4g (quatro gramas) da droga cocaína, acondicionada em 10 (dez) invólucros de plásticos translúcidos fechados por nó; e (iii) 6,9g (seis gramas e nove decigramas) da droga cocaína em forma de crack, acondicionada em 15 (quinze) pedras em invólucros de plásticos translúcidos

fechados por nó, sem autorização e em desacordo com determinação regulamentar. Consta nos autos, que foi encontrada a quantia de R\$ 30,00 (trinta reais) em dinheiro, bem como 01 (um) telefone celular.

Notificada (fls. 138), apresentou defesa preliminar (fls. 142/143).

Recebida a denúncia em 15 de abril de 2019 (fls. 151).

Citada (fls. 172), apresentou resposta à acusação (fls. 177).

Prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que, ausente causa de absolvição sumária (fls. 184).

Produziu-se prova oral com a oitiva das testemunhas (fls. 243), a ré tornou-se revel (fls. 264).

Ao final, manifestaram-se as partes por memoriais escritos. O Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal (fls. 268/273). A Defesa pleiteou, preliminarmente, pela nulidade da violação de domicílio, bem como a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação de figura penal mais branda, e o afastamento da pena pecuniária (fls. 277/290).

É a síntese do relatório.

Fundamento e Decido.

A ação penal é procedente.

Preliminarmente, rejeito a alegação defensiva de nulidade de prova em razão de invasão de domicílio, uma vez que, conforme exaustivamente já analisado pelo e. Superior Tribunal de Justiça “é cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Vale dizer, em outras palavras, que o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência do recorrente, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses”.

Ainda, o STF, responsável pela uniformização da interpretação constitucional, fixou no Tema 280 de sua Repercussão Geral (RE 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 05/11/2015, DJe 10/05/2016) a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

Assim, o ingresso da polícia, sem mandado judicial, será legítimo quando as circunstâncias do caso concreto indicarem estar ocorrendo situação de flagrante delito no interior da residência.

No caso, verifico que havia fundada razão para que os Policiais Militares acreditassem que havia uma infração penal em curso, já que, além de terem recebido denúncia anônima, conversaram informalmente com a testemunha Antônio sobre a acusada pedir dinheiro para comprar drogas, como também as vendia, e ter envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

Ademais, de acordo com o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o consentimento do morador é uma das hipóteses que excepcionam a regra da inviolabilidade do domicílio, e, conforme relatado pelos policiais militares, a própria ré autorizou a entrada deles no imóvel.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. Preliminar. Crime permanente indicando situação de flagrância apta a autorizar a pronta ação da Polícia, independentemente de mandado, sem se desprezar o fato de o réu haver franqueado o acesso dos policiais ao imóvel. Inteligência dos artigos 5º, XI, da Constituição Federal e 150, § 3º, II, do Código Penal. Nulidade inexistente. Matéria rejeitada. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão corroborada pelos relatos seguros e coesos de policiais militares, que apreenderam 68 tijolos de maconha na residência do réu. Condenação mantida. Pena-base acima do piso em face de circunstância desfavorável representada

pela grande quantidade do entorpecente apreendido, consoante artigo 42 da Lei nº. 11.343/06. Atenuante da confissão espontânea colidente com a prisão em flagrante, consoante jurisprudência da SUPREMA CORTE, lamentada a inércia da Justiça Pública a impedir a revisão do julgado nesta parte. Quadro adverso colidente com o privilégio descrito no artigo 33, § 4º, daquela mesma Lei Extravagante e com a substituição da corporal por restritivas de direitos também incabível diante do montante da reprimenda. Regime inicial fechado único adequado ao crime de natureza hedionda, sem se ignorar o quadro adverso também inconciliável com retiro menos severo.

Provimento tão-só ao apelo da acusação (Apelação Criminal nº // 1503215-65.2020.8.26.0047, Rel. Farto Salles, 6ª Câmara de Direito Criminal, j.18/11/2021). Ainda: Habeas Corpus Tráfico de droga Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar Alegações de ausência de fundamentação da decisão objurgada, dos requisitos da prisão preventiva e de provas do cometimento do delito, bem como da ocorrência de violação de domicílio Inadmissibilidade Descabida a pretendida discussão aprofundada, nos angustos lindes do remédio heroico, acerca da prova da prática do crime - Manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, mercê da gravidade in concreto do crime, evidenciada pela quantidade significativa de droga apreendida (204,21 gramas de maconha), reveladora da periculosidade do agente, além da sua reincidência Descabimento, por inadequação, de qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.403/2011, mormente em face da norma inscrita no artigo 282, inciso II, do mesmo Código. Hipótese, ademais, em que não há se falar em violação de domicílio in casu, máxime porque nada impede que qualquer pessoa adentre em residência alheia, durante o dia ou à noite, independentemente da vontade do morador, para efetuar prisão em flagrante. De mais a mais, por se tratar o tráfico de crime de natureza permanente, sua consumação se protraí no tempo, autorizando a prisão em flagrante, a qualquer momento e por qualquer pessoa, independentemente de mandado judicial, enquanto estiver sendo perpetrado pelo agente. Mandamus parcialmente conhecido e denegado. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2246319-13.2020.8.26.0000; Relator (a): Moreira da Silva; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Casa Branca - 1ª Vara; Data do Julgamento: 07/12/2020; Data de Registro: 07/12/2020).

A materialidade delitativa encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02), boletim de ocorrência (fls. 11/13), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), laudo de constatação (fls. 17/20), guia de depósito judicial (fls. 39), laudos periciais de objetos (fls. 96/97 e 98/99), laudo pericial do local (fls. 108/112), bem como pela prova oral colhida.

Também a autoria criminosa da ré, evidenciou-se.

Em Juízo, as testemunhas, Wagner Fragoso e Clovis Araújo da Silva, ambos Policiais Militares, disseram que estavam em serviço, quando receberam a informação de que no bairro rural de Taiacubepa, teria chegado denúncia anônima de que uma mulher estaria extorquindo um senhor de idade, morador do bairro, para uso e tráfico de entorpecentes. As compras eras feitas com o dinheiro extorquido do senhor de idade. Foram até o local, e tiveram uma conversa informal com o senhor de idade, mora sozinho, confirmou que a acusada pedia dinheiro, e por saber que a acusada era envolvida com o tráfico, entregava dinheiro, por medo. Em seguida, patrulharam o bairro a procurada da acusada. Abordaram a mulher com as características que foram passadas. Na revista pessoal, foi encontrado entorpecentes e aparelho telefone celular. A acusada informou que havia mais drogas em sua residência. Foram até a residência da acusada, a mesma indicou o local das drogas, encontradas os entorpecentes dentro do guarda-roupa e gavetas. A acusada afirmou que o senhor de idade dava dinheiro por conta própria. A acusada residia sozinha. Não abordou a acusada em fatos anteriores. A acusada vendia as drogas para uma pessoa chamada "Amarelo". O senhor de idade não tinha nenhuma relação com a acusada. A acusada autorizou verbalmente a entrada em sua residência. Tiveram o endereço da acusada por denúncia anônima.

Em solo policial, a testemunha Antônio de Souza Aguiar, narrou que há cerca de 15 anos, conhece Claudia, o procurava para pedir dinheiro para comprar remédios e outras coisas, era casada com traficante, com medo, dava dinheiro a ela, depois o

marido da acusada morreu, mesmo assim, continuou dando dinheiro, por medo. Nunca foi ameaçado pela acusada para dar dinheiro a ela. No dia de hoje, a polícia foi até sua casa procurando pela acusada, tendo alegado o acima exposto, depois, os policiais foram embora. Os policiais o procuraram de novo e disseram que encontraram drogas na casa da acusada, foram até a Delegacia.

A acusada, Claudia Francisca Lau, tornou-se revel.

Em solo policial, narrou que pela tarde, estava indo para a casa de Antônio, para ir conversar com ele para pedir dinheiro emprestado, mas antes de chegar lá, policiais militares a abordaram na rua, e a colocaram na viatura, pedindo seus documentos. Nada foi encontrado em seu poder, levando-a para sua casa, e ali, nada encontraram de ilícito. Foi agredida com uma ripa na perna e nas costas, depois foi levada para a base da Polícia Militar em Taiacupeba, ali foi revistada por uma policial feminina, na sequência, foi trazida a esta Unidade Policial. Alega que a droga apreendida não estava em sua casa e nem em poder da mesma. É usuária de crack a cerca de vinte e cinco anos. Conhece Antônio a cerca de quinze anos, sempre pegava dinheiro com ele, era amante de Antônio nestes quinze anos, mas o dinheiro que pedia a ele nunca lhe foi dado pelo motivo de ser amante, e sim, porque eram amigos, cujo dinheiro usava para comprar drogas. Nunca ameaçou ou extorquiu Antônio para conseguir dinheiro, sendo que ele dava o dinheiro por vontade própria. Nunca foi presa ou processada pela Justiça. Tem sete filhos, estão sendo criados por sua família, não mora junto com nenhum deles. Não tem dependente deficiente físico. Com efeito, a autoria criminosa está suficientemente demonstrada.

Ademais, o certo é que o fato de ser usuário, por si só, não afasta a traficância, pois é justamente pela venda que o usuário satisfaz o consumo. Desta forma, o elemento subjetivo do tipo penal restou plenamente configurado, tendo em vista a ciência da ré em relação às drogas.

Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo e tenha em depósito a substância entorpecente.

Já decidiu o STF que “a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012).

No que tange à aplicação da causa especial de redução, na forma do artigo 33 parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, entendo pertinente reconhecê-la, tratando de ré primária e não comprovada sua participação em organização criminosa.

Nesse lastro, o conjunto probatório permite concluir, com segurança, pela responsabilidade da acusada quanto aos fatos descritos na inicial.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, em atenção às circunstâncias do caso em tela e ao que dispõe o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, e o artigo 59, do Código Penal, mantenho a pena no mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausente circunstâncias atenuantes e/ou agravantes.

Na terceira fase, o benefício da redução de pena trazido pela Lei nº 11.343/06 deve ser concedido a acusada. Isso porque, o § 4º, do artigo 33, de referida Lei, dispõe que as reprimendas referentes aos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo poderão sofrer redução de 1/6 a 2/3, caso seja o agente primário, conforme se infere de sua Folha de Antecedentes de fls. 241/242, depreendendo-se que não se trata de traficante habitual, e tendo em conta que não restou minimamente comprovada qualquer ligação do acusado com organizações criminosas.

Desta forma, diminuo a reprimenda em 1/2 (metade), perfazendo, assim, sanção de 02 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 250 dias-multa. Destaque-se que, em relação à referida causa de diminuição, o próprio Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal admitem a consideração da quantidade e da qualidade de droga apreendida para balizar o patamar de diminuição a ser aplicado.

Nesse sentido:

“PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU PATAMAR MÁXIMO.

IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão de direito versada nestes autos diz

respeito à não-aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo. 2. O fato de o paciente possuir bons antecedentes e boa conduta social, apesar de permitir a incidência da causa especial de diminuição de pena, não obriga sua aplicação em seu grau máximo, mormente quando, na espécie, o réu possui personalidade voltada ao mundo do crime. 3. Foi grande a quantidade de droga apreendida, o que reforça a impossibilidade de se reduzir a pena em 2/3 (dois terços). 4. Habeas corpus denegado" (STF -HC nº 100755/AC -Min. Rel. Ellen Gracie -2ª Turma -j. 20.04.10).

E (...). "São requisitos para que o condenado faça jus à causa de redução da pena prevista no parágrafo 4.º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Reconhecidas tais circunstâncias, é imperiosa a aplicação da minorante. 4. O art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da nova Lei de Drogas. 5. Na hipótese, a redução da pena no patamar máximo (2/3) se justifica na pequena quantidade de droga apreendida (0,08g de crack), assim, o percentual de redução da pena atende à proporcionalidade necessária e suficiente para reprovação do crime" (STJ -HC nº 157763/MG -Min. Rel. Laurita Vaz -5ª Turma -Dje 29/11/2010).

Ante a inexistência de provas acerca da condição econômica da acusada, o valor unitário de cada dia-multa, deve ser estabelecido no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo da conduta.

O regime será o aberto, conforme artigo 33, do Código Penal, aliado às peculiaridades do caso concreto e diante da primariedade da acusada. Entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Nesse sentido:

"O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal" (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). "Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida" (STJ, HC 206015/RJ).

Diante de todo o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR a ré CLAUDIA FRANCISCA LAU, qualificada nos autos, como incurso no artigo 33, caput, e §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime aberto, e o pagamento de 250 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, à mingua de maiores informações acerca da capacidade econômica da ré.

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Ainda, impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista.

Declaro a perda do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas, nos termos da Lei nº 11.343/06 (fls. 14/15).

Autorizo a incineração das drogas apreendidas nos moldes do artigo 524 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, se o caso.

Autorizo a destruição do bem de valor inexpressivo apreendido - sacola - (fls. 14/15).

Quanto ao telefone celular, autorizo o leilão, desde que apagados, por funcionário da empresa responsável pela alienação, os dados pessoais que podem gerar constrangimento (imagem e honra - CF, art. 5º X). Tratando-se de aparelhos sem

valor comercial, fica autorizada a destruição (fls. 14/15).

Tendo sido solta em razão da decisão de fls. 73/75, e não havendo, por ora, motivos para a revogação do benefício, poderá apelar desta em liberdade.

Após o trânsito em julgado:

(i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;

(ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;

(iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;

(iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);

(v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Custas na forma da lei, ressalvado o previsto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil, que expressamente revogou o art. 12 da Lei 1.060/50.

P.I.C.

Mogi das Cruzes, 05 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA